

0001861-30.2008.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... não afasta a possibilidade da consumação do tráfico de drogas.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. (...) ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA E CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE (...) III - Para que se configure o crime impossível pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001861-30.2008.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001861-30.2008.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 761/2008 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 761/2008 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 293/2008 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JANAÍNA LOUREIRO DE MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

JANAÍNA LOUREIRO DE MELO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de fevereiro de 2008, por volta das 13h30min, no estabelecimento prisional denominado Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, localizado na Estrada do Taboão do Pareteí, Taboão, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, aproximadamente 65g (sessenta e cinco gramas) da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular.

A denúncia foi recebida em 23 de dezembro de 2008 (fls. 96) após defesa preliminar

(fls. 77/88).

Em 13 de setembro de 2010 ocorreu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 164). Citada às fls. 202.

Resposta à acusação fls. 204/205.

Houve o levantamento do prazo prescricional em 22 de maio de 2019 (fls. 206).

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 212).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas (fls. 247 e 261) e interrogatório da ré (fls. 320).

Ao final, as partes apresentaram memoriais escritos (fls. 324/329 e 334/344).

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06, boletim de ocorrência de fls. 14/15, auto de exibição/apreensão de fls. 21/22, laudo de constatação de fls. 24/25 e 47/49, e depoimentos tomados.

Também, a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha Cylaine Tassinari Silva Moretti, agente penitenciária, disse que realizaram a revista de praxe na acusada, na época tinha revista íntima. Quando a acusada agachou visualizaram que tinha algo em sua genitália e pediram para que retirasse. Ela alegou que estava passando mal. Foi com ela ao hospital. O médico examinou a ré e retirou o invólucro contendo os entorpecentes. Ela confessou.

A testemunha Paulo Rogério Lugoboni não se recorda dos fatos.

A acusada Janaína Loureiro de Melo confessou a prática delitiva, relatando que estava indo visitar o seu ex-marido. Ele tinha uma "conta" de drogas na prisão, por isso pediu para que ela levasse o entorpecente. Fez isso somente uma vez. Levou drogas e um maço de cigarros com um chip, de uma pessoa que pegou na porta da penitenciária. Foi feita revista íntima.

Restou claro que a acusada concorreu para a prática do delito, tendo consigo a substância entorpecente, o que basta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Não há como acolher o pleito absolutório, nem tanto a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, notadamente pelo flagrante e depoimentos tomados que descreveram o delito com riqueza de detalhes atribuindo a autoria a ré, corroborado pela confissão da mesma.

Nem mesmo cabe alegação de nulidade do processo por revista vexatória. Ainda que a lei estadual mencionada pelo combatente defensor se posterior aos fatos aqui julgados, entende o Superior Tribunal de Justiça que, caso haja suspeitas de que o visitante do estabelecimento prisional esteja portando objetos ilícitos, é possível a realização de revista íntima com o objetivo de preservar a segurança do estabelecimento, desde que a busca seja dentro dos parâmetros constitucionais e legais e sem nenhum procedimento invasivo.

Confira-se: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE REVISTA ÍNTIMA DE VISITANTE DE PRESÍDIO. NÃO OFENSA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVASIVO. AGRADO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A alegação de incidência do óbice de admissibilidade do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 126 consubstancia inovação recursal, porquanto não levantada em momento oportuno por ocasião das contrarrazões ao recurso especial"

(EDcl no AgRg no AREsp 1770430/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 5/4/2021). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, para fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro

dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo. 3. No caso dos autos, a recorrida foi surpreendida com entorpecentes dentro de sua vagina, em procedimento de revista íntima ocorrida no interior de estabelecimento prisional, não havendo falar em ilegalidade, pois observados todos os parâmetros legais e constitucionais, sem a ocorrência de nenhum procedimento invasivo. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1959230/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Tal entendimento já foi aplicado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso desses itens no presídio. 2. Depois de ser acionado o detector de metais, a própria acusada, após a constatação de que havia evidências da ocultação de objeto, retirou o entorpecente do seu corpo (45 g de maconha, acondicionados no interior de sua vagina), o qual seria entregue a seu companheiro, preso no local. 3. Não há nenhuma notícia de que a acusada haja sido eventualmente forçada pelas agentes penitenciárias a submeter-se ao procedimento para a remoção da substância entorpecente do seu corpo, tampouco de que o ato haja sido realizado de forma vexatória, humilhante ou constrangedora. 4. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa. Trata-se. tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos. 5. Ante fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente se for feita dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu nos autos. Precedentes. 6. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (STJ, REsp 1681778/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).

Ficou constatado, ainda, que a ré foi encaminhada ao hospital, onde o médico ginecologista a atendeu e retirou o invólucro contendo a substância entorpecente, não havendo que se falar em revista "vexatória" (fls. 18/20).

Por fim, não há de se falar em crime impossível. A existência de revista na entrada dos visitantes ao estabelecimento prisional não afasta a possibilidade da consumação do tráfico de drogas.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. (...) ALEGADA ATÍPICIDADE DE CONDUTA E CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE (...) III - Para que se configure o crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto é necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal não sofra o mínimo risco. A mera existência de revista, rigorosa ou não, na entrada dos visitantes ao presídio não afasta a possibilidade da prática do tráfico de drogas, porquanto é possível que o agente, burlando a segurança, alcance o seu objetivo de ingressar no estabelecimento com a substância entorpecente. O crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, motivo pelo qual a simples conduta de trazer consigo substância entorpecente já é suficiente para a sua caracterização que independe da efetiva entrega das drogas ao destinatário. (...)." (TJPR, 4ª CCR, ApCr 0011525-62.2016.8.16.0174, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, DJPR 12/04/2019).

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas restou comprovada, visto que o delito foi cometido em estabelecimento prisional. No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, entendendo pertinente reconhecê-la, tratando-se de ré primária, além de inexistente comprovação de que integrante de organização criminoso.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, sendo a ré primária, sem antecedentes atestados nos autos (fls. 215/216), bem como não se tratando de quantidade expressiva de entorpecentes, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), mas, em virtude da Sumula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido à acusada. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação da acusada com organizações criminosas, além da quantidade de droga apreendida. Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), perfazendo, assim, sanção de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Verifica-se: "PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado"(STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime "(STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não

são socialmente recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave. Neste sentido: “O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar a ré JANAÍNA LOUREIRO DE MELO, devidamente qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 33, “caput”, §4º, c.c o artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

A ré poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA